

Comercio Electrónico

I.- Introducción.-

El problema de elaborar una definición de comercio electrónico radica en que el mismo no constituye de por sí un concepto jurídico sino económico, circunstancia que dificulta su aprehensión desde el derecho.

La mayoría de las definiciones elaboradas varían según se utilice una mayor o menor amplitud en lo concerniente a los medios utilizados para comerciar. Así, el Ministerio de Economía de la Nación, en oportunidad de presentar su informe sobre el desarrollo del fenómeno¹, lo definió como *“el conjunto de transacciones comerciales y financieras realizadas por medios electrónicos. Esto es el procesamiento y la transmisión electrónica de datos, incluyendo texto, sonido e imagen”*. En función de la definición se incluirían dentro del concepto no solo las transacciones comerciales sino también cualquier negocio jurídico como la publicidad, edición o cualquier otro servicio.

Otros autores entienden que el concepto debe restringirse a aquellas hipótesis en donde las transacciones económicas se producen mediante la utilización de redes de computadoras abiertas o cerradas. En tal sentido, Luz Clara define al comercio electrónico como *“Cualquier forma de transacción o intercambio de información comercial, basada en la transmisión de datos sobre redes de comunicación como Internet”*²

Por último, y atento las particularidades que conlleva, es posible restringir el concepto de comercio electrónico a las operaciones comerciales llevadas a cabo mediante la Internet. La justificación de dicha diferencia es más que meramente tecnológica: El carácter distribuido de la Internet, unido a su extensión mundial deriva en una serie de problemas jurídicos específicos tanto en cuanto a la jurisdicción y ley aplicable como las formas de expresión de la voluntad que permiten diferenciar el fenómeno de las transacciones realizadas mediante redes punto a punto o incluso del

¹ Ministerio de Economía, *Primer Informe de Progreso del Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico y Comercio Exterior*, Buenos Aires, 1998

² Luz Clara, *“Manual de Derecho Informático”*, Ed. Nueva Tesis, 2001 Asimismo ver la definición en Matías Altamira, *Norma MERCOSUR para Defensa del Consumidor en Internet*, disponible en <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=3210>

tradicional sistema de Intercambio electrónico de datos (EDI)³ utilizado para transacciones financieras.

Contratos Electrónicos:

El contrato informático puede ser definido como *todo contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red de telecomunicaciones*⁴

Tal como se diferenciaba al momento de tratar el contrato informático, el contrato electrónico no se define por su objeto sino por los medios utilizados para su realización: La existencia de un intercambio telemático de información durante la celebración o el cumplimiento del contrato: Al igual que con el comercio electrónico, es posible hablar de un contrato electrónico en sentido amplio, comprendiendo todo tipo de medio electrónico de intercambio de información (telefónica, fax, etc) o en sentido estricto, incluyendo solamente aquellos casos en que el intercambio se realiza mediante la intervención de dos o más ordenadores. Asimismo, según la opinión doctrinaria que elijamos podemos circunscribir el concepto a los contratos celebrados mediante medios informáticos⁵ o incluir aquellos en los que el componente electrónico se presenta en cualquier etapa del contrato⁶

A los efectos de este trabajo, utilizaremos un concepto restringido, toda vez que la problemática a analizar, en particular los problemas de la expresión de la voluntad, ley aplicable y competencia, se relacionan en forma directa con la celebración del convenio.

Tal es el principio consagrado en el artículo 11.1 de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico elaborada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), que dispone que *“En la formación de un contrato, de no convenir las partes otra cosa, la oferta y su aceptación podrán ser expresadas por medio de un mensaje de datos. No se negará*

³ Este sistema se caracteriza por elaborar en el ordenador del emisor de un mensaje estructurado con empleo de códigos normalizados, previamente acordados, de esta forma al recibirse el mensaje podrá ser tratado en forma automatizada por el sistema receptor, ganando en seguridad y eficiencia. Las características técnicas y la inversión necesaria para su funcionamiento hace que su utilización se restrinja a grupos de cerrados de empresarios.

⁴ Moro Alvarez, *La contratación en el comercio electrónico: Luces y sombras* disponible en <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=968>

⁵ Ver por ejemplo Brizzio, Claudia R., *“Contratación electrónica y contratos informáticos*, La Ley, 2000-A

⁶ Ver, Lorenzetti, Tratado de los contratos, Tomo III, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2000.

validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación un mensaje de datos”⁷

Si bien el principio general de los contratos informáticos es su validez, cabe destacar que no todos los contratos pueden ser celebrados por medios electrónicos. En los países que se ha regulado el instituto, es usual que se restrinja la posibilidad de la celebración de ciertos convenios mediante medios electrónicos. Así, por ejemplo, la directiva de europea sobre comercio electrónico 2000/31 permite a los estados miembros excluir de sus legislaciones la posibilidad de utilizar medios electrónicos para celebrar contratos de caución o que transmitan la propiedad de inmuebles, entre otros negocios jurídicos⁸.

Aun en los casos en que no existe legislación específica es posible que algunos contratos queden excluidos de la posibilidad de su realización por medios informáticos. Esto sucedería en los casos que el ordenamiento requiera la existencia de formas solemnes de celebración del negocio jurídico, las que no puedan ser realizadas en forma digital.

A este respecto, si bien el art. 6 de la ley 25.506 de firma digital permite dar por cumplido el requisito de la forma escrita mediante la utilización de un documento digital, esto no permite asimilarlo a formas particulares como la escritura pública, habida cuenta de los requisitos establecidos para los libros de protocolo por el art. 998 y 1005 del Código Civil, por lo que debe rechazarse la posibilidad de su utilización cuando el ordenamiento requiera tales instrumentos.

Clasificaciones del Contratos Electrónicos:

Según elemento a tener en cuenta, podemos clasificar al comercio electrónico de las siguientes maneras:

1.- Según los sujetos intervinientes: A este respecto debe diferenciarse según estemos frente a relaciones que se establezcan con consumidores o entre empresas directamente. Esta es la clasificación más conocida, diferenciando entre comercio electrónico entre empresas (*bussines to bussines* o B2B) o entre empresas y el consumidor (*Bussines to consumer* B2C). La presencia de una relación de consumo conlleva la aplicación de los principios de

⁷ Disponible en http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/05-89453_S_Ebook.pdf

⁸ Art 9 inc 2 de la Directiva 2000/31 del 8 de Junio de 2000. Disponible en su texto oficial en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:0016:EN:PDF>

protección a los particulares establecidos por la legislación de cada país así como por los acuerdos internacionales⁹.

2.- Según el tracto contractual: En este sentido debe separarse aquellas transacciones cuya cumplimiento se realiza en forma completa por Internet de aquellas en las que alguna de las etapas del contrato debe realizarse en forma tradicional. En general la posibilidad de acceder a contenidos digitales (ya sean estos bienes inmateriales como software o simplemente servicios en línea) permite la interacción vía web de los contratantes hasta la satisfacción de su obligaciones, circunstancia que presenta nuevas dificultades respecto a la posibilidad de control y imposición de gravámenes por parte de los estados. De la misma forma, la hipótesis de cumplimiento tradicional de las obligaciones, y en particular, el envío de bienes materiales entre los contratantes, conlleva costos ocultos y nuevas relaciones contractuales (contrato de transporte de mercaderías, seguros, etc.) que exceden al marco de la contratación electrónica.

3.- Según la forma de manifestación de la voluntad: En este acápite debe diferenciarse los métodos que conllevan una simultaneidad en la declaraciones de oferta y aceptación por parte de los contratantes de aquellos en las que el método utilizado permite que las manifestaciones se encuentren separadas por un período de tiempo. Esta diferenciación técnica conlleva una consecuencia jurídica importante respecto del momento en el cual se debe considerar realizada tal manifestación.

Competencia Internacional y las cláusulas de prorrogación de competencia:

Uno de los primeros problemas que se suscita al analizar la contratación electrónica es la definición de la competencia jurisdiccional para entender en los posibles conflictos derivados del contrato. La existencia de una relación establecida por medio electrónicos plantea el problema no solo de la distancia física, típico de los contratos entre ausentes sino asimismo, la existencia de una red distribuida que separa a los celebrantes del contrato del lugar donde se procesa la expresión de voluntad, los servidores.

Ello no es óbice para encontrar una solución aplicable al instituto. Lorenzetti sostiene que el comercio electrónico solo implica un nuevo paso en la abstracción de los negocios jurídicos: frente a la pérdida de materialidad de la relación es necesario obtener nuevo factor de imputación de los efectos jurídicos, operación que es

⁹ A respecto ver, Carlos Dionisio Aguirre, *Desarrollo desde la perspectiva de la defensa del consumidor electrónico – el papel del conocimiento y la contratación*, disponible en <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=3492>

posible realizar mediante los medios legales a disposición del operador jurídico¹⁰.

En dicho sentido, el ordenamiento argentino regula el tema de la jurisdicción internacional de los contratos tanto en normas de carácter interno (art. 1215 y 1216 del código civil) como fuentes del derecho público internacional (Tratados de derecho civil internacional de Montevideo de los años 1889 y 1940, Protocolo en materia contractual de buenos aires de 1994). Asimismo y en lo referente a operaciones comerciales es posible prorrogar la jurisdicción, salvo que la misma sea exclusiva de la nación argentina o que el pacto de prorroga de competencia se encuentre prohibido.

A este respecto es usual incluir dentro de las cláusulas del contrato la prórroga de competencia a favor de un tribunal específico, habitualmente el del domicilio de la parte que estableció los términos del acuerdo. En tal sentido, tanto la jurisprudencia como la doctrina han entendido que en los casos en que la renuncia al fuero establecido por ley implique dejar a la otra parte en un estado de indefensión jurídica, la cláusula es violatoria del principio de defensa en juicio y consecuentemente contraria al orden público argentino.

Sin embargo debe tenerse en cuenta la simple prorroga no implica la nulidad de la cláusula sino que es necesario la demostración de un abuso de la posición negocial de la parte predisponente en el acuerdo¹¹.

De no haberse previsto el pacto o en el caso que el mismo sea declarado nulo en sede judicial, el actor puede demandar al deudor en la Argentina en los casos en que este último tuviera domicilio en el territorio o en la hipótesis que el cumplimiento del contrato debería realizarse en la república.

En tal sentido, la jurisprudencia de la CSJN ha sido particularmente amplia respecto de habilitar la jurisdicción argentina en contratos internacionales. Así, en "*Exportadora Buenos Aires S.A. c/Holliday Inn's Worldwide Inc.*" sostuvo que en los casos de concurrencia foros, con el fin de asegurar el acceso a la justicia, permite que cualquier lugar de cumplimiento de las obligaciones en la república argentina habilita la jurisdicción nacional para entender en el conflicto¹².

Ley Aplicable al contrato electrónico internacional

¹⁰ Lorenzetti, Ricardo, *Comercio Electrónico*, pags. 199, Ed Abeledo Perrot, Buenos Aires 2001. En el mismo sentido, Lorenzetti, Ricardo, *Tratado de los contratos*, T III, Cap LXVII, Ed. Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2000

¹¹ Ver Pablo Bolotnikoff, *Informática y Responsabilidad Civil*, La Ley, Bs As 2004

¹² CJSN, 20/10/08, LL 2000-A-2003, citado por Heriberto Simón Hocsman, *Negocios en Internet*, Ed Astrea, Buenos Aires, 2005.

Relacionado con la competencia jurisdiccional, otro de los problemas que suscita la contratación electrónica es la definición de la legislación aplicable. En la hipótesis de contratos internacionales, el principio es el de la autonomía de la voluntad, el cual, sin embargo, no es absoluto manteniendo numerosas excepciones. Entre las principales cabe destacar la existencia de fraude, la existencia de un orden público internacional o la tutela de ciertos sujetos jurídicos considerados negocialmente más débiles.

En particular, puede suceder que el régimen jurídico elegido no guarde vinculación alguna con el negocio a regular. En tales casos, es habitual que los tribunales –en especial en países como Estados Unidos o Canadá- rechacen las convenciones establecidas de esta forma, por entender que no guardan relación razonable con el contrato.

Para el caso que las partes no hayan establecido convención alguna, el ordenamiento jurídico prevé una serie de normas supletorias de carácter indirecto para determinar el ordenamiento jurídico que regula la situación. En nuestro ordenamiento, el art. 1210 del Código Civil establece el principio de la ley del lugar del cumplimiento del contrato. Sin embargo es posible que las características del contrato impliquen la existencia de múltiples lugares ejecución. En tales casos, la jurisprudencia ha entendido que debe utilizarse el lugar de la prestación más característica del contrato en detrimento de las demás.

Para los casos en que no pueda establecerse el lugar de cumplimiento de la prestación, la doctrina entiende que debe aplicarse supletoriamente el art. 1205 del Cod. Civil y utilizarse el lugar de celebración del contrato para definir el régimen aplicable.

Una particularidad del problema se presenta respecto de los contratos que involucran a consumidores. En tal sentido debe tenerse en cuenta que la regulación establecida por la ley 24240 de defensa del consumidor, así como legislaciones similares establecidas en otros países, constituyen normas de orden público destinadas a la protección de la parte mas débil de la ecuación contractual, por lo que no pueden ser dejadas de lado por medio de convención al contrario.

Es habitual que las empresas que comercian por Internet incluyan este tipo de previsiones, con el fin de limitar los costos judiciales derivados de la comercialización de sus productos. En función de lo analizado, en principio se invalidaría la mayoría de las cláusulas establecidas en lo que respecta a la legislación aplicable a la operatoria.

Sin embargo, la declaración de nulidad de dichos acuerdos implicaría un aumento en los costos de comercialización de las empresas, que deberían conocer la legislación de todos los países

donde se sitúen sus clientes. En la práctica, ello derivaría en que las empresas limitarían la posibilidad de contratar con los consumidores extranjeros, hecho que sería todavía más contraproducente para estos últimos que las posibles consecuencias derivadas del acuerdo.

Atento estas consideraciones, algunos autores han planteado la validez de dichos acuerdos en los casos en que la elección de la normativa aplicable no derive en un abuso de la posición negocial de la empresa¹³.

Otros autores han diferenciado las hipótesis de que se haya realizado comercialización de los productos por parte del proveedor o si simplemente el consumidor accedió a la página por propia iniciativa. Así, Sergio Maldonado sostiene que la directiva europea 97/7/CE habilita la aplicación de la legislación del domicilio del consumidor en los casos en que la empresa haya realizado publicidad en el lugar o mantenido una sucursal en el país. En función de ello, la posibilidad de acceso vía web a los productos no impide la aplicación de las reglas del lugar del establecimiento principal de la empresa¹⁴.

Para solucionar la falta de seguridad jurídica existente actualmente se está evaluando la conveniencia de suscribir tratados poder adoptar un criterio uniforme respecto de este tema. Es así como algunos comentaristas han propuesto actualizar la Convención de las Naciones Unidas sobre la Venta Internacional de Bienes para que se incluyan las transacciones de comercio electrónico. En este sentido también la Unión Europea se ha pronunciado sobre la conveniencia de un marco legal único¹⁵, así como la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) que ha dado a conocer sus iniciativas, aunque a la fecha no existen acuerdos en aplicación¹⁶.

La Formación del Contrato

Si la doctrina tradicionalmente ha sostenido que el contrato se perfecciona con la aceptación lisa y llana de una oferta, el problema de la determinación del momento en que podemos considerar

¹³ Ver Bolotnikoff, Pablo, *op cit*, pag 311 sigs.

¹⁴ Ver Sergio Maldonado *Argumentos a favor de la aplicación de la ley de origen en operaciones transfronterizas de comercio electrónico*, disponible en www.onnet.es

¹⁵ COM (98) 50 final, 04.02.1998 Globalisation and the Information Society. The Need for Strengthened International Coordination

¹⁶ En este sentido ver Bolotnikoff, Pablo, *op cit*, pag 311 sigs y Antonio José Santander Rengifo (Director), *Compraventa por Internet y situación del consumidor en el Perú*, disponible en

http://www.alfa-redi.com/apc-aa-alfaredi/img_upload/9507fc6773bf8321fcad954b7a344761/compraventa.pdf

celebrado un contrato informático deriva en la necesidad de analizar dos cuestiones básicas: La primera el concepto de oferta en la web y la segunda, los métodos de manifestación de la voluntad de los contratantes.

El concepto de oferta

Es habitual que los sitios dedicados al comercio electrónico publiciten sus productos y servicios mediante una breve descripción de las características y precio en sus páginas, permitiendo a los usuarios accedan a las mismas y los adquieran. Se vuelve imperativo analizar si esta publicación constituye una oferta vinculante o si, por el contrario, puede ser revocada de así considerarlo conveniente.

Según lo normado por el art. 1148 del Código Civil, habrá oferta cuando el ofrecimiento fue hecho *“a persona o personas determinadas sobre un contrato especial, con todos los antecedentes constitutivos de los contratos”*. En el mismo sentido, el art. 454 del código de comercio establece que *“las ofertas a personas indeterminadas (...) no obligan a quien las ha hecho”*. Del texto de ambos artículos aparece claro que la oferta, para ser catalogada como tal, debe ser autosuficiente, conteniendo en su formulación todos los elementos que permitan su aceptación lisa y llana. La oferta a personas indeterminadas no obliga a quien la realiza, constituyendo en realidad una invitación a realizar ofertas por parte de los teóricos aceptantes.

Asimismo debe tenerse en cuenta que la regulación de la oferta en el código civil permite a su autor la retractación de así considerarlo conveniente. El art. 1150 indica que *“Las ofertas pueden ser retractadas mientras no hayan sido aceptadas, a no ser que el que las hubiera hecho, hubiese renunciado a la facultad de retirarlas o se hubiere obligado al hacerlas, a permanecer en ellas hasta época determinada”*

En el derecho comparado, el proyecto la UNCITRAL¹⁷ en su art.12 sigue manteniendo que la *propuesta de un contrato que no dirigida a personas determinadas se tendrá por una invitación para presentar ofertas*, salvo que indique la intención del que hace la propuesta de quedar obligado en caso de aceptación. Dicha solución sigue los lineamientos de convenciones anteriores, en particular la Convención de Viena sobre compraventa de mercadería, aunque se

¹⁷ UNCITRAL, *Aspectos jurídicos del comercio electrónico. Contratación electrónica: disposiciones para un proyecto de convención*, 42 período de Sesiones, Nueva York, 17-21 noviembre 2003

proponen a debate del Grupo de trabajo otras alternativas más flexibles¹⁸

Sin embargo, estos principios se modifican sustancialmente en los casos en que estemos frente a una relación de consumo. En tales casos la oferta se rige por los principios establecidos por la ley 24240 de defensa del consumidor, la que establece en su art. 7 que *“la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados obliga a quien la realiza durante el tiempo en que se realiza, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y finalización, así como también sus modalidades, condiciones y limitaciones. La revocación de la oferta hecha pública es eficaz una vez que haya sido difundida por medios similares a los empleados para hacerla conocer”*. En similar inteligencia, el art. 8 de la ley establece que las precisiones formuladas por la publicidad forman parte de la oferta y resultan obligatorias para el oferente.

Similar regulación puede encontrarse en el derecho comprado. Así, el art. 4 de la directiva 97/7/CE establece la obligación de informar las condiciones de contratación al consumidor antes del contrato, las cuales deben mantenerse. De la misma forma, la resolución para el MERCOSUR sobre defensa del consumidor en Internet plantea la obligación de la debida información respecto de los productos y servicios ofrecidos¹⁹

Formas de expresión de la aceptación:

Se ha discutido respecto a si los contratos electrónicos deben ser considerados contratos entre ausentes o entre presentes. Al respecto debe diferenciarse entre los contratos que se resuelven mediante un formulario incorporado a la propia página, de aquellos en los que el contrato se celebra mediante el intercambio de comunicaciones electrónicas.

En el primero de los casos, existe una forma de interacción instantánea entre los contratantes que impide la existencia de lapso entre oferta y aceptación del contrato. En tales casos no es posible hablar de una retractación sobreviniente de la oferta.

Sin embargo, el contrato puede celebrarse mediante el intercambio de comunicaciones electrónicas, en forma similar a los contratos celebrados mediante correspondencia epistolar. En tales

¹⁸ En el mismo sentido, el art. 14 de la convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercadería define la oferta a personas indeterminadas como una mera invitación a escuchar propuestas.

¹⁹ Resolución 21 del Grupo Mercado Común MERCOSUR, adoptada mediante resolución 104/05 de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación.

hipótesis se presenta el problema de determinar en que momento se debe considerar realizada la aceptación.

Este problema no constituye una simple cuestión teórica, ya que es posible que el ofertante se retracte en el lapso comprendido entre la manifestación de voluntad del aceptante y su recepción. Dependiendo cuando consideremos realizada la aceptación, el contrato ya se habría celebrado (o no) y por tanto, la retractación podría devenir en invalida.

Expresión de la voluntad mediante formularios Web: Clic and Warp Agreement y Browse Agreement.

En ambos casos nos encontramos con contratos de adhesión realizados mediante un formulario incluido dentro de la programación de la página, de forma tal que el acuerdo se celebra íntegramente mediante esta.

Los *clic and warp agreements* es la denominación del acuerdo en que la aceptación se realiza mediante un cuadro de diálogo²⁰ ofrecido por el programa donde el usuario interacciona con el mouse sobre una interfaz prefijada (normalmente un botón de aceptar o declinar) para manifestar su voluntad. Esta ventana impide el acceso a la prestación, funcionando como una barrera hasta que el usuario acepte los términos del contrato.

Históricamente el término proviene de los contratos conocidos como *shrink warp agreement*. Estos contratos se utilizaban para la comercialización de software y recurrían a la apertura del envoltorio plástico que protegía al packaging como forma de aceptación de la licencia de uso del programa. Los tribunales han discutido la validez de tales acuerdos en base a que la mayoría de las veces el acceso a los términos y condiciones implicaba abrir el plástico, por lo que los usuarios aceptaban la licencia antes de haberla leído.

La jurisprudencia norteamericana se ha expedido en forma reiterada respecto a la validez del acuerdo realizado de esta manera. Como principio general, y al igual que los *shrink warp agreement*, la validez de los *click agreement* está supeditada al real conocimiento por parte del usuario del contenido del contrato. Así, en 1998 en el caso *Hotmail Corporation v. Van Money Pie Inc., et al.*,²¹ la corte de estado de California, entendió que los usuarios habían incumplido la cláusula que les impedía enviar y recibir correo no deseado desde su cuenta en Hotmail, toda vez que habían aceptado los términos y

²⁰ En interfaces gráficas, un cuadro de diálogo es una ventana especial para mostrar información al usuario o para obtener de éste una respuesta. Son llamados así porque permiten una especie de diálogo entre el sistema y el usuario

²¹ Citado por Bolotnikoff, Op cit, pag. 302, disponible en su versión original en <http://cyber.law.harvard.edu/property00/alternatives/hotmail.html>

condiciones contenidos en la página. En tal caso, el contrato fue presentado con anterioridad al acceso al servicio, posibilitando el conocimiento por parte de los suscriptores.

Sin embargo, en *Williams v. America Online, Inc.*²² la corte de Massachusset entendió que la prórroga de competencia establecida en los términos y condiciones no era ejecutable, atento que los usuarios no habían conocido los mismos al momento de instalar el programa. En el caso se discutió la instalación por parte de America On Line de un software que impedía el funcionamiento de programas de la competencia en la máquina de los usuarios. La demandada alegó la existencia de una cláusula de prórroga de la competencia (convención que el derecho americano acepta como válida) incluida en la licencia. La corte rechazó el pedido argumentando que el programa no impedía a los usuarios la instalación del software sin haber leído los términos y condiciones, los cuales eran optativos²³, por lo que la empresa no había dado suficiente noticia de los mismos.

En los *browse agreement* en cambio no es necesario manifestar la voluntad en forma expresa: La utilización de los servicios del sitio web hacen presumir la conformidad de los términos y condiciones de la página por parte de los usuarios, los que quedan contractualmente obligados en los términos establecidos de antemano.

Usualmente, las condiciones de contratación se encuentran incluidos mediante un hipervínculo colocado al final de la página, bajo la denominación “*legales*” o simplemente “*términos y condiciones*”. Atento ello, los usuarios pueden utilizar los servicios del sitio o descargar sus productos sin acceder a los mismos ni conocerlos.

La legalidad de dichos acuerdos es objeto de debate. Así en *Specht v. Netscape Communications Corp*²⁴, los tribunales del estado de Nueva York dictaminaron que la mera utilización de un servicio de descarga no conlleva la aceptación de los términos y condiciones establecidos en la página. En el caso, los demandantes plantearon una violación a su derecho a la privacidad derivado de las funciones ocultas de un programa de la empresa Netscape. Esta a su vez introdujo una cuestión de competencia aduciendo que los términos

²² Sup Court Mass 2/8/2001 citado en De la Maza/Cruz, Contratos por Adhesión en plataformas electronicas, Alfa Redi, n° 53 Junio de 2003. Disponible en su idioma original en <http://www.internetlibrary.com/pdf/Williams-America-Online.pdf>

²³ El cuadro de dialogo no mostraba los términos de la licencia sino dos botones *Acepto* o *Leer*. Si se presionaba *acepto* el programa se instalaba sin permitir al usuario leer la licencia.

²⁴ Citado por De la Maza/rúz, Op cit, disponible en su versión en idioma original en <http://www.nysd.uscourts.gov/courtweb/pdf/D02NYSC/01-07482.PDF>

de uso del sitio consignaban la jurisdicción arbitral del estado de California. Los usuarios quedarían obligados a cumplir dichas estipulaciones con la descarga del programa, de la misma forma que en un *click agreement*.

El rechazo de la pretensión de la empresa se fundamenta en una diferenciación esencial entre ambos tipos de acuerdo. Tal como sostuvo la corte, el inicio de la descarga del producto –y en realidad cualquier otra actividad en la web- no tiene como objeto la manifestación de voluntad sino la obtención de un bien inmaterial. La inexistencia de un cuadro de dialogo que permita expresar llanamente la conformidad con el contrato previamente expuesto impide considerar que se ha celebrado una convención.

Debe tenerse en cuenta que la validez del acuerdo browse se haya supeditada a la existencia de un aviso claro por parte de proveedor de servicios informáticos respecto a la existencia de las condiciones de contratación. Así, De la Maza y Cruz²⁵ sostienen la necesidad de asegurar la facilidad de acceso del usuario a los mismos, evitando que la utilización de términos o gráficos que lo oculten o dificulten su lectura. En el mismo sentido, los términos deben encontrarse en la página principal del sitio o por lo menos en la página de acceso al mismo.

Contratos Celebrados mediante comunicaciones electrónicas:

A diferencia de los contratos celebrados directamente sobre la página web, las convenciones realizadas mediante comunicaciones electrónicas plantean un lapso entre la expresión de la declaración de voluntad aceptando la oferta y la actual recepción por parte del ofertante. En tal sentido, estos acuerdos mantienen todas las características de los tradicionales contratos entre ausentes (distancia geográfica/temporal), pudiendo por tanto aplicar las soluciones establecidas para dicho instituto.

El principal problema es la definición del momento en que se da por formado el consentimiento, variando las soluciones según el ordenamiento que se tome en consideración. Las principales teorías son las siguientes:

1.- Teoría de la expresión de la voluntad: El consentimiento se da por realizado con la mera expresión de la voluntad, con prescindencia de la comunicación al ofertante.

2.- Teoría de la cognición: La voluntad se da por formada con el conocimiento de la otra parte. Esta es la solución adoptada por la mayoría de las legislaciones del derecho continental europeo.

²⁵ De la Maza/Cruz, Op cit

3.- Teoría de la recepción: La voluntad se da por formada con la recepción de la manifestación de la voluntad por parte del ofertante.

4.- Teoría de la emisión: La voluntad se da por constituida cuando el aceptante envía la notificación a la contraparte, con prescindencia de la actual recepción.

El ordenamiento argentino decepciona esta última doctrina en el art. 1154 cuando establece que *“La aceptación solo hace perfectos el contrato desde que ella se hubiese mandado al proponente”*. Similar principio se expresa el art. 215 cuando trata la contratación entre agentes.

Excepcionalmente, el código civil prevé la utilización de la teoría del conocimiento en dos casos: El art. 1155 prevé la posibilidad de retractar la aceptación antes de que la misma llegue a conocimiento del ofertante; mientras que el art. 1149 prescribe que en los casos de incapacidad o muerte sobreviniente del proponente, el contrato se considerará celebrado en los casos en que el ofertante tuvo conocimiento de la aceptación y no cuando esta se envió.

Asimismo debe tenerse en cuenta que en las hipótesis de relaciones de consumo, la ley 24240 en su art. 34 otorga al consumidor el derecho a revocar la aceptación durante el plazo de 5 días de recibida la cosas adquirida por medios telefónicos o postales. Esta solución tiene su fundamento en la necesidad de evaluar las características reales del producto y no puede ser renunciada. Similares soluciones se establecen tanto en la normativa de protección de consumidores para el MERCOSUR como en la directiva europea 97/7/CE²⁶.

Medios de Pago Electrónicos

La denominación medios de pago electrónicos engloba a los medios de satisfacer las obligaciones que utilicen total o parcialmente una red de computadores para su realización.

Si bien es posible realizar los pagos de las operaciones realizadas en Internet en forma tradicional²⁷, la posibilidad de tal realización lo torna engorroso.

²⁶ La directiva europea establece en su art. 7 un plazo de 7 días hábiles para resolver, mientras que la resolución 21 del MERCOSUR se limita en su art. 2 a establecer la obligación de los ofertas de informar las políticas de reembolso y devolución aplicables a la operatoria.

²⁷ Es el sistema tradicional en los sitios de remate, donde comprador y vendedor celebraban el acuerdo en línea y luego entregaban el producto y el dinero en forma tradicional. Hoy en día estos sitios han ampliado su función de meros intermediarios, incorporando sistemas de intermediación financiera.

Frente a esto se elaboraron distintas propuestas comenzando con la utilización de tarjetas de crédito para realizar los pagos. Sin embargo, y aún con el cifrado de información del cliente, la comunicación se encontraba sujeta a la posibilidad de acceso no autorizado por parte de terceros, circunstancia que le restaba confianza.

Actualmente existen empresas que brindan soluciones de intermediación financiera para realizar las compras por Internet. Asimismo, ha surgido el llamado “dinero electrónico”, sistema que acredita un crédito mediante el depósito por anticipado de sumas de dinero que queda disponible en un dispositivo que queda en poder del depositario²⁸

La utilización de tarjetas de crédito presenta dos problemas fundamentales. El primero es considerar cuando se produjo el pago en sí mismo, mientras que el segundo deriva de la necesidad de asegurar las transacciones realizadas.

Para entender el problema de la acreditación del pago, es necesario observar que en realidad existen dos obligaciones diversas. Una vez acreditada la operación entre el cliente y el sitio de Internet, surge en la entidad de crédito la obligación de abonar las sumas presentadas al cobro, toda vez que se ha obligado a cubrir las dichas deudas mediante el contrato de tarjeta de crédito. Sin embargo, al mismo tiempo nace la obligación del cliente de abonar las sumas pagadas y acreditadas en su resumen. Se trata en suma de dos obligaciones independientes.

Sin embargo siempre existe el riesgo de que se imputen al titular de la tarjeta operaciones que no realizadas. En tal caso, la ley 25.506 de tarjetas de crédito permite la impugnación del saldo de tarjeta en un plazo de 30 días desde que fue recibido. El emisor en tal caso debe acusar recibo de la impugnación dentro de los siete días siguientes y presentar los comprobantes o fundamentos del débito en el lapso de 15. En el caso de operaciones realizadas por Internet se presenta el problema de la ausencia de comprobantes firmados por el titular, lo que dificultaría la prueba.

Respecto a la seguridad, actualmente existen varios sistemas de seguridad destinados a encriptar las comunicaciones y reguardar los datos financieros de los titulares de la tarjeta. Los dos principales son el SSL (secure socket layer) desarrollado por Netscape y el SET creado por las empresas Visa y Mastercard.

El SSL no es, en realidad, un sistema de pago sino un mecanismo de carácter general destinado a asegurar las comunicaciones realizadas vía web. Si bien es el más sencillo,

²⁸ Ver Jose Mariano Maltese, *Pago Electrónico en la Argentina. Diversos medios de pago relacionados con el e-commerce* disponible en <http://www.portaldeabogados.com.ar/derechoinformatico/1023ecommerce.htm>

presenta algunas objeciones al momento de su aplicación. En primer lugar, la conexión segura se establece entre los contratantes solamente dejando de lado al intermediario financiero. En segundo, transmite los datos sin corroborar al comerciante, solución que permite el abuso por parte de una parte inescrupulosa ya el sitio sea perjudicado con la presentación de una tarjeta fraudulenta o que se carguen consumos en detrimento del titular de la misma.

El SET, en cambio, constituye un protocolo destinado específicamente al comercio electrónico, incorporando a todos los sujetos de la transacción. De la misma forma elimina muchas de las inseguridades de la transacción, ya que evita que el comerciante conozca los datos de la tarjeta, al mismo tiempo que impide a la entidad financiera conocer los consumos realizados. El mayor problema para la adopción de este sistema es que resulta engorroso tanto para el usuario como para el sitio web, siendo necesaria la inversión en software y equipos, los cuales muchas veces no son compatibles entre sí²⁹.

Asimismo es posible la utilización de intermediarios financieros, siendo quizás el más conocido PayPal. La operatoria en tales casos necesita que el cliente ingrese en el sitio del intermediario la información de su tarjeta, siéndole entregado un número de identificación para realizar las transacciones en los sitios adheridos. Estos, a su vez, acreditan la compra con el intermediario, quien procede a imputar el débito en la tarjeta del usuario.

Este sistema soluciona parcialmente el problema de la seguridad, evitando tener que ingresar la información en cada una de las operaciones. Sin embargo, no evita la posibilidad de ataques a las bases del intermediario, que sigue manteniendo la información sensible.

Por último, otro sistema posible es el llamado dinero digital. Tal como ya analizáramos en tales casos, el cliente deposita, adquiere o consigna los valores recibiendo a cambio una tarjeta inteligente o una clave donde se registran los valores disponibles³⁰.

En los Estados Unidos, el sitio INTERNET CASH provee a distintos comercios las tarjetas prepagas. El cajero que vende la tarjeta debe pasarla por un sistema magnético para activarla. Así le dará al cibercomprador un número de identificación personal o PIN. Acto seguido, será necesario realizar la suscripción al sitio, de manera de poder utilizar la tarjeta comprada. Luego de eso, ya será posible empezar a comprar todo tipo de productos en las páginas adheridas³¹.

²⁹ Ver Fernando Ramos Suarez, Protocolos SET, Alfa Redi N° 3 Octubre de 1998.

³⁰ Ver Hocsman Negocios en Internet, pag. 135 y sigs.

³¹ Ver Jose Mariano Maltese, op cit.